



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-01483672- -APN-CME#MP - OPI 305

VISTO el Expediente N° EX-2018-01483672- -APN-CME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación traída a consulta se notificó el día 9 de enero de 2018 y consiste en la creación de la firma NUTRIEN LTD como compañía matriz tanto de la firma ARGIUM INC. como de la firma POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC. y el consecuente cambio de control de las sociedades controladas previamente en forma exclusiva por los accionistas de la firma ARGIUM INC.

Que la transacción se instrumentó mediante la celebración de un Acuerdo de Fusión entre las firmas POTASH CORPORATION OF SASKATECHEWAN INC., y ARGIUM INC., en virtud del cual cada accionista de ambas empresas intercambio cada una de sus acciones por acciones de la firma NUTRIEN LTD., y posteriormente la firma NUTRIEN LTD., intercambió cada acción de POTASH CORPORATION OF SASKATECHEWAN INC., por UNA (1) acción de la firma POTASHCORP ACQUISITION CO., y cada acción de la firma ARGIUM INC., por UNA (1) acción de la firma ARGIUM ACQUISITION CO., continuando las firmas ARGIUM INC., y POTASH CORPORATION OF SASKATECHEWAN INC., como subsidiarias indirectas, CIEN POR CIENTO (100%) controladas por la firma NUTRIEN LTD.

Que la operación traída a consulta no genera efectos en la República Argentina, conforme indica el Artículo 3° de la Ley N° 25.156 y por lo tanto la misma no se encuentra sujeta a la obligación establecida en el Artículo 8° de la citada ley.

Que para que la Ley N° 25.156 resulte aplicable, las personas a las que hace mención en su Artículo 3° deben realizar actividades económicas en el territorio nacional, o fuera del país, en la medida en que sus actividades puedan producir efectos en el mercado nacional.

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que la mencionada ex Comisión Nacional ha emitido el Dictamen de Mayoría de fecha 11 de diciembre de 2018, correspondiente a la “OPI. 305” aconsejando a la señora Secretaria de Comercio disponer que la operación traída a consulta consistente en la creación de la sociedad NUTRIEN LTD como compañía matriz tanto de ARGIUM INC. como de POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC. y el consecuente cambio de control de las sociedades controladas previamente en forma exclusiva por los accionistas de ARGIUM INC. no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, por no encuadrar en lo indicado por el Artículo 3° de la citada norma.

Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos allí vertidos.

Que, asimismo el señor Vocal de la citada ex Comisión Nacional Don Pablo TERVISAN (M.I. N° 23.471.818) ha emitido el Dictamen Voto Particular de fecha 8 de diciembre de 2018 correspondiente a la “OPI 305” donde aconseja a la señora Secretaria de Comercio a que la operación traída en consulta, consistente en la combinación de los negocios de AGRIUM INC. y POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC. por medio de una serie de actos de organización societaria, que incluyen aunque no se limitan a la creación de una newco - denominada NUTRIEN LTD- que se desempeña como la parent -o controlante última- de las dos empresas fusionadas, y el consecuente cambio de control sobre PROFERTIL S.A. y AGROSERVICIOS PAMPEANOS S.A. -controladas previamente en forma exclusiva por los accionistas de ARGIUM INC.- se encuentra sujeta a la obligación de notificación prescripta en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, lo cual debe ser efectivizado por las partes de la operación o por la sociedad comercial continuadora; Hacer saber a la consultante que el presente voto disidente ha sido emitido fundamentalmente sobre la base de la información y documentación que se ha proporcionado y que obra en el expediente de referencia; por lo que, si lo presentado y consignado fuera falso o incompleto, ello tornaría -total o parcialmente- inaplicables los conceptos allí vertidos.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen de mayoría al cual cabe remitirse en honor a la brevedad incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 18 y 58 de la Ley N° 25.156, los Decretos N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18 y la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Excéptuase al control previo, establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, la operación traída a consulta por la firma NUTRIEN LTD.

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a las consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de mayoría fecha 11 de diciembre de 2018, y al Dictamen Voto particular de fecha 8 de diciembre de 2018, ambos correspondientes a la “OPI. 305”, emitidos por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como IF2018-64739048-APN-CNDC#MPYT, e IF-2018-64034637-APN-CNDC#MPYT, respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Opi 305 - Dictamen Mayoria No Notifica

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente EX-2018-01483672- -APN-CME#MP caratulado “OPI 305 - NUTRIEN LTD, POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC Y AGRIUM INC S/OPINIÓN CONSULTIVA” del registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del Artículo 8° del Decreto PEN N° 89/2001, reglamentario de la Ley N° 25.156 por parte de las firmas NUTRIEN, LTD., en su carácter de última controlante de POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC., y AGRIUM INC.

I. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

1. NUTRIEN, LTD (en adelante “NUTRIEN”) es una compañía recientemente constituida de conformidad con las leyes de Canadá, que, como consecuencia de la operación aquí consultada, se convirtió en la compañía matriz de las firmas AGRIUM INC. (en adelante “AGRIUM”), y POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC. (en adelante “POTASH CORP”).
2. NUTRIEN es una compañía pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y Toronto. No se encuentra controlada por ninguna persona o empresa ya que sus acciones están atomizadas entre un gran número de accionistas, que en forma previa eran accionistas de AGRIUM y de POTASH.
3. POTASH CORP era la sociedad matriz del grupo PotashCorp. Es una compañía pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York y de Toronto, debidamente constituida de conformidad con las leyes de Canadá. Es una empresa de fertilizantes radicada en Canadá, dedicada a la producción y venta a nivel global de potasio, fosfato y nitrógeno.
4. POTASH CORP no posee activos ni subsidiarias en la República Argentina, y su contacto con nuestro país está dado por las exportaciones de potasio que realiza a través de una empresa denominada CANPOTEX LTD., sobre la cual posee el 33% del capital social, junto con AGRIUM y MOSAIC CANADA CROP NUTRITION LP, quienes también poseen el 33%.
5. CANPOTEX LTD., es una sociedad canadiense, distribuidor global exclusivo del potasio producido por sus accionistas, que opera en forma independiente de sus accionistas. No tiene activos ni participaciones en Argentina, solo ventas por exportaciones de potasio a nuestro país. Sus accionistas son: POTASH CORP

con el 33%, MOSAIC CANADA CROP NUTRITION LP con el 33% y ARGIMUM con el restante 33%. Luego de la transacción CANPOTEX LTD pasará a estar controlada en un 50% por NUTRIEN y en un 50% por MOSAIC CANADA CROP NUTRITION LP (en adelante “MOSAIC”).

6. En relación a CANPOTEX LTD las consultantes informaron con fecha 10 de octubre de 2018 que con fecha 27 de diciembre de 2017 CANPOTEX LTD y cada uno de sus accionistas (ARGIMUM, POTASH y MOSAIC) celebraron un Contrato en virtud del cual modificaron el Contrato de Accionistas existente. Surge de dicho contrato que tanto ARGIMUM como POTASH acordaron retirarse como accionistas de CANPOTEX LTD a la fecha de esta transacción. Como consecuencia de la transacción, NUTRIEN sustituyó a ARGIMUM y POTASH como accionista de CANPOTEX LTD. Asimismo informan que en el contrato también se contempló la reorganización de las tenencias accionarias en CANPOTEX LTD, de forma tal que NUTRIEN y MOSAIC pasaron a ser propietarios del 50% de las acciones cada una.

7. ARGIMUM era la sociedad matriz del grupo Argium, debidamente constituida de conformidad con las leyes de Canadá, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York y de Toronto, dedicada a la producción y provisión de nutrientes para cultivos. A su vez es proveedor agrícola minorista de insumos, servicios y soluciones para cultivos.

8. PROFERTIL S.A. (en adelante “PROFERTIL”), es una sociedad anónima debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, en donde ARGIMUM posee el 50% de las acciones, e YPF S.A. posee el 50% restante. PROFERTIL es una empresa dedicada a la producción y comercialización de fertilizantes, en particular urea granulada y amoníaco. A su vez vende otros fertilizantes y prepara mezclas especiales para nutrir el suelo y optimizar el rendimiento de los cultivos de manera sustentable.

9. AGROSERVICIOS PAMPEANOS S.A. es una sociedad anónima, controlada exclusivamente por ARGIMUM, que constituye una red de minoristas que suministra insumos y servicios a los agricultores en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Los productos que proveen incluyen fertilizantes, productos químicos para la protección de cultivos, semillas y servicios agronómicos.

II. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

10. Con fecha 11 de septiembre de 2016 POTASH CORP y ARGIMUM celebraron un Acuerdo de Fusión¹ en virtud del cual cada accionista de POTASH CORP y cada accionista de ARGIMUM intercambió cada una de sus acciones, por acciones de la recientemente constituida NUTRIEN. Posteriormente, NUTRIEN intercambió cada acción de POTASH CORP por una acción de una compañía recientemente creada denominada POTASHCORP ACQUISITION CO, y cada acción de ARGIMUM por una acción de una compañía recientemente constituida denominada ARGIMUM ACQUISITION CO, continuando ARGIMUM y POTASH como subsidiarias indirectas, 100% controladas y de propiedad de NUTRIEN.

11. Como resultado de la operación, los accionistas de POTASH CORP por un lado y de ARGIMUM por otro, resultarían titulares del 52% y 48% de las acciones de NUTRIEN, respectivamente, y tanto ARGIMUM, con sus empresas controladas y POTASH CORP con las suyas, resultarán subsidiarias 100% controladas por NUTRIEN.

12. Las partes consultantes entienden que la operación aquí informada no estaría sujeta a la obligación de notificar establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, por cuanto se encuadraría en la excepción establecida en el inciso c) del Artículo 10 de la misma norma, toda vez que, con anterioridad a la transacción, NUTRIEN no era titular de activos ni acciones en sociedades en Argentina.

III. EL PROCEDIMIENTO

13. El día 9 de enero de 2018, se presentó la apoderada de NUTRIEN a fin de requerir una opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° del Decreto N° 89/01 y Resolución SCT N° 26/06.

14. Con fecha 12 de enero de 2018, esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento a los consultantes comunicándoles que el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 89/01 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.

15. Tras sucesivos requerimientos efectuados por esta Comisión Nacional, con fecha 6 de diciembre de 2018 las partes consultantes efectuaron una presentación cumplimentando lo requerido por esta Comisión Nacional, pasándose las actuaciones a despacho.

IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

16. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que ésta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudieren implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

17. Dado que, en la operación traída a consulta, el volumen de negocios de las empresas involucradas no se indica como inferior a los umbrales previstos en el Artículo 8° LDC, se ha de abordar seguidamente la cuestión que consiste en determinar con precisión si la operación que consiste en el cambio de control de ARGIMUM y POTASH CORP, y en consecuencia de ambos grupos empresarios, se encontraría exenta de la obligación de notificación establecida en el ya mencionado Artículo 8° de la LDC.

18. Las partes indicaron en su presentación inicial y actualizaron en su presentación de fecha 15 de enero de 2018, que en lo que respecta a la Argentina la transacción implica el cambio de control sobre dos compañías. Por un lado, sobre PROFERTIL, pasando de un control conjunto entre ARGIMUM e YPF a un control conjunto entre NUTRIEN e YPF, y por otro lado sobre AGROSERVICIOS PAMPEANOS S.A., empresa controlada exclusivamente por ARGIMUM, que luego de la transacción pasaría a estar controlada en última instancia por NUTRIEN. Asimismo, resulta necesario agregar que como resultado de la operación respecto de CANPOTEX LTD., se pasó de un control conjunto entre ARGIMUM, POTASH CORP y MOSAIC CANADA CROP NUTRITION LP, a un control conjunto entre NUTRIEN y MOSAIC CANADA CROP NUTRITION LP.

19. Corresponde considerar que, como consecuencia de la operación sujeta a consulta, NUTRIEN, sociedad vehículo creada a los efectos de la presente operación, pasa a controlar a ARGIMUM y sus subsidiarias, y a POTASH CORP y sus subsidiarias, teniendo esta última únicamente una participación del 33% sobre CANPOTEX LTD., sobre la cual ARGIMUM, de forma previa a la presente operación, ya poseía también el 33% de dicha empresa. Reiteramos en este apartado que, como consecuencia de la operación aquí consultada, ARGIMUM y POTASH CORP se retiraron como accionistas de CANPOTEX LTD., y como resultado de la reorganización de las tenencias accionarias, NUTRIEN y MOSAIC pasaron a ser propietarios del 50% de CANPOTEX LTD., respectivamente. Por lo tanto, como resultado de la transacción que nos ocupa, no surge una relación económica nueva de la ya existente.

20. Por otra parte, en lo que respecta al mercado argentino, el Acuerdo de Fusión solo modificó la identidad de la empresa que en última instancia ejerce el control conjunto sobre PROFERTIL (esto es ARGIMUM), sin crear ninguna relación económica sobre ninguna otra compañía controlada por POTASH CORP. o ARGIMUM o ambas en conjunto (CANPOTEX LTD.)

21. En el caso bajo estudio, los accionistas de ARGIMUM y de POTASH CORP constituyeron una nueva empresa denominada NUTRIEN, la que se convirtió en última instancia en la compañía matriz tanto de ARGIMUM como de POTASH CORP.

22. No cabe dudas que, en definitiva, el Acuerdo de Fusión lo que genera es un cambio de control, de exclusivo a conjunto respecto de las sociedades controladas previamente en forma exclusiva por los accionistas de ARGIMUM, por un lado, y ahora en forma conjunta con los accionistas de POTASH CORP,

por el otro, a través de la nueva sociedad NUTRIEN.

23. Ahora bien, dado que POTASH CORP no posee activos ni subsidiarias en la Argentina, salvo por las exportaciones de potasio que realiza la empresa CANPOTEX LTD., que también co controla junto con ARGIMUM y MOSAIC CANADA CROP NUTRITION LP, lo cierto es que la operación en el país, no viene a generar ningún efecto económico nuevo que el que ya existía respecto de las empresas que controlaba ARGIMUM en nuestro país (esto es PROFERTIL S.A., AGROSERVICIOS PAMPEANOS y exportaciones de CANPOTEX LTD.).

24. Siguiendo esa línea de ideas, las consultantes en su presentación de fecha 3 de agosto de 2018 refuerzan esta teoría explicando que la transacción no tiene efectos en la República Argentina ya que no modifica el panorama competitivo y por ende no se justifica la aplicación de un procedimiento de control previo de concentraciones.

25. Asimismo, las consultantes indican que antes de la conclusión de la transacción, ARGIMUM tenía ventas directas a la Argentina, una participación indirecta de control/co-control en AGRO SERVICIOS PAMPEANOS S.A. y PROFERTIL S.A. respectivamente y una participación en CANPOTEX LTD. Respecto de POTASH CORP, ésta no tuvo ventas ni activos en nuestro país y solo tiene una participación en CANPOTEX LTD. En la misma oportunidad agregan que, luego del cierre, NUTRIEN simplemente ocupa la posición de ARGIMUM respecto a la Argentina.

26. En tal sentido el Artículo 3º de la Ley N° 25.156 explica que “Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional”. Como explicamos en el punto anterior, no se advierte que la operación bajo consulta genere nuevas relación o efectos en el mercado nacional, ni modifique los ya existentes.

27. Dicho todo lo anterior, y por las consideraciones efectuadas, esta Comisión Nacional entiende que la operación traída a consulta no genera efectos en la República Argentina, conforme indica el Artículo 3º de la Ley N° 25.156 y por lo tanto la misma no se encuentra sujeta a la obligación establecida en el Artículo 8º de la Ley N° 25.156.

V. CONCLUSIÓN

28. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA CON VOTO DE SU MAYORÍA aconseja a la Señora SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO disponer que la operación traída a consulta, consistente en la creación de la sociedad NUTRIEN LTD como compañía matriz tanto de ARGIMUM INC. como de POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC. y el consecuente cambio de control de las sociedades controladas previamente en forma exclusiva por los accionistas de ARGIMUM INC. no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8º de la Ley N° 25.156, por no encuadrar en lo indicado por el Artículo 3º de la citada norma.

29. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

30. Elévese el presente Dictamen a la Señora SECRETARIA DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO DE LA NACIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Sr. Vocal Dr. Pablo Trevisán suscribe su voto por Dictamen separado.

¹ Todo ello a partir de la fecha de cierre la tuvo lugar el día 1 de enero de 2018.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen

Número:

Referencia: OPI 305 - VOTO PARTICULAR

/// VOTO PARTICULAR del Sr. VOCAL Dr. PABLO TREVISÁN.

Agregar a Voto de Mayoría en Expediente EX-2018-01483672- -APN-CME#MP caratulado “OPI 305 - NUTRIEN LTD, POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC Y AGRIMUM INC S/OPINIÓN CONSULTIVA” del registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

I. CONSIDERANDO

1. Que, preliminarmente y en mérito a la brevedad, el suscripto deja constancia que hace suyos -en todo cuanto no se oponga ni contradiga el presente voto- los considerandos 1 a 15 del voto de la mayoría de los miembros de esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
2. Que, tal como se consigna en el voto mayoritario, el 9 de enero de 2018 se ha presentado, por ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, solicitud de Opinión Consultiva, conforme a lo dispuesto por el art. 8 del Decreto PEN N° 89/2001 y por la Resolución SCT N° 26/2006, fin que se decida sobre la obligación de notificar, en los términos de la Ley 25.156, la operación que se describe sucintamente a continuación.
3. Que, a los fines de precisar el objeto del presente, es necesario consignar que la operación consultada, de naturaleza compleja conforme surge del Acuerdo de Transacción^[1] celebrado el 11 de septiembre de 2016 en el extranjero, se materializó entre AGRIMUM INC. -en adelante también AGRIMUM- y POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC. -en adelante también POTASH CORP- (sociedades ambas constituidas conforme a las leyes de Canadá) con la finalidad de combinar y unificar la dirección y gestión de todos los negocios de AGRIMUM y POTASH CORP. De la combinación referida y como consecuencia de una serie de actos de organización societaria, AGRIMUM INC y POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC. devinieron en subsidiarias indirectamente controladas por una misma nueva *parent* (*newco* -nueva compañía-) creada, en el marco de la fusión, bajo la denominación de NUTRIEN LTD -en adelante también NUTRIEN-, cuyo objeto social es gestionar y administrar unificadamente los negocios combinados de AGRIMUM y POTASH CORP.
4. Que, de los elementos aportados y para el supuesto planteado por la consultante, conforme al análisis efectuado por el dicente, se desprenden las consideraciones que se consignan a continuación.
5. Que, si bien ambas partes del Acuerdo de Transacción (“*Arrangement Agreement*”) están radicadas en el

exterior -Canadá-; conforme expresa la presentante, AGRIMUM tenía en la República Argentina, previo a la operación notificada, participación en el capital societario (en los porcentuales que se consignan en cada caso entre paréntesis) de PROFERTIL S.A. (50%) y AGROSERVICIOS PAMPEANOS S.A. (100%).^[2]

6. Asimismo, la presentante informa, por una parte, que POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC no tiene presencia ni actividad directa en Argentina^[3]; sin embargo, por otra parte, declara que la sociedad antes mencionada es titular de acciones representativas del 33% del capital social (en igual porcentual que las co-partícipes AGRIMUM y MOSAIC COMPANY)^[4] de CANPOTEX LIMITED –en adelante también CANPOTEX- sociedad que realiza exportaciones de potasio a la República Argentina.

7. De esa información -proporcionada y obrante en autos- se desprende, por una parte, que indubitadamente AGRIMUM realizaba, previo a la operación en consulta, actividades económicas en nuestro país; y, por la otra parte -complementariamente a los fines de su significación- que las referidas exportaciones de potasio realizadas por CANPOTEX, representaron, sin duda alguna, una actividad económica indirecta de las tres (3) empresas co-partícipes de tal empresa mixta, de entre ellas POTASH CORP, con efectos en la realidad económica de la República Argentina.

8. La potasa de las minas de POTASH CORP en Saskatchewan producida para su uso fuera de América del Norte -conforme consta en el *Annual Report* 2016 de POTASH CORP- se vende exclusivamente a través de CANPOTEX. Además, las exportaciones del potasio de POTASH CORP a América Latina -a través de CANPOTEX- representan el 33% del total de sus ventas *off shore*.^[5] Si a lo expuesto se agrega, según lo informado por la propia consultante, que las exportaciones de potasio realizadas por CANPOTEX con destino a Argentina ascendieron en 2017 a U\$S 5.365.200, representando un 32,23% de las importaciones totales de Argentina,^[6] a criterio de este VOCAL, no puede aseverarse que tales exportaciones sean insignificantes, como tampoco puede ponerse en duda su “habitualidad”^[7] y “frecuencia”^[8], y mucho menos podría negarse que POTASH CORP tenía una actividad económica indirecta y con efectos en la Argentina.

9. Continuando con el hilo argumental, adicionalmente, el dicente puede apreciar : **i.** que, el conjunto de actos jurídicos que se instrumentan para el logro de la combinación de los negocios de AGRIMUM y POTASH CORP (fusión) consisten en modos legalmente expresados de realizar una concentración económica;^[9] **ii.** que, el volumen de negocios de las empresas involucradas, no se indica por la presentante como inferior a los umbrales legales de *minimis*;^[10] **iii.** que, puede afirmarse, por manifiesta evidencia, que la operación en cuestión no encuadra en los incisos a), b) ni d) del artículo 10 de la Ley 25.156; **iv.** que, en lo que respecta al inciso e) del artículo 10 de la Ley 25.156, si se analiza que la *newco* resultante de la fusión (sociedad que gestiona y administra los negocios combinados mencionados) adquiere el control indirecto conjunto sobre PROFERTIL S.A.^[11]; con más el control indirecto exclusivo sobre AGROSERVICIOS PAMPEANOS S.A. (hoy denominada NUTRIEN AG SOLUTIONS S.A.) y además el control conjunto de CANPOTEX (que ha exportado con destino a Argentina en 2017 U\$S 5.365.200), ni siquiera ligeramente es posible aseverar, cualquiera fuera el monto de la operación, que el valor de los activos cuyo control adquiere NUTRIEN es menor o igual a \$ 20.000.000; **v.** que, finalmente, respecto al inciso c) del artículo 10 de la Ley 25.156, que es esgrimido por la consultante como fundamento de su argumento respecto a que la operación en consulta se trataría de actos jurídicos no sujetos a la obligación de notificación, es preciso resaltar que el citado inciso c) literalmente establece “*Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo anterior las siguientes operaciones (...): Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina; (...)*”. En consecuencia, al no ser la empresa objeto del cambio de control en cuestión una única empresa argentina; ni tampoco ser la adquirente del control una única empresa extranjera, hechos que justificarían un encuadre de la operación en la exención llamada *first landing*, sino que el control de PROFERTIL y AGROSERVICIOS PAMPEANOS es adquirido por un nuevo grupo económico resultante de una fusión y combinación de negocios de dos

empresas (AGRIMUM y POTASH CORP) que, previo a la operación consultada, eran agentes económicos independientes en el mercado, en todos aquellos negocios diversos de la exportación del potasio.

10. Además, dado que el artículo 3° de la ley 25.156 recepta en su texto la doctrina internacionalmente denominada “doctrina de los efectos”, estableciendo que “*Quedan sometidas a la disposiciones de la ley 25.156 todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro (...) que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional...*”; conforme lo antes explicitado, puede afirmarse sin hesitación que; (a) la actividad económica indirecta de POTASH CORP tiene efectos en la República Argentina, y por ende POTASH CORP también estaría *prima facie* sometidas a las disposiciones de la ley 25.156, y (b) que, los actos jurídicos celebrados para materializar la combinación de los negocios de POTASH CORP con los negocios de AGRIMUM produce efectos en el mercado nacional.

11. Surge de lo expuesto, y descartado todo encuadre de la operación en lo estatuido por el art. 10 de la Ley 25.156 y en las exenciones del art. 8 del Dec. PEN N° 89/2001, que la existencia de un cambio en el control sobre PROFERTIL S.A. y sobre AGROSERVICIOS PAMPEANOS S.A., ambas sociedades constituidas y con actividad en la República Argentina, que han pasado de ser controladas -conjunta y exclusivamente respectivamente- por AGRIMUM a ser controladas por NUTRIEN –sociedad creada como consecuencia de la fusión y combinación de negocios de AGRIMUM y POTASH CORP-, permite al dicente concluir que la operación traída en consulta, cuyo cierre se produjo el 1 de enero de 2018^[12], encuadra en los en los artículos 3° y 6° de la Ley 25.156, lo que determina que se trata de un acto de concentración económica que debe ser notificado en los términos del artículo 8° de la Ley 25.156 (vigente al tiempo del cierre de la operación).

II. CONCLUSIÓN

Por los considerandos antes expuestos, este VOCAL de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja, a la Sra. SECRETARIA DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO DE LA NACIÓN, resolver conforme se detalla a continuación:

PRIMERO: Que la operación traída en consulta, consistente en la combinación de los negocios de AGRIMUM INC. y POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC. por medio de una serie de actos de organización societaria, que incluyen aunque no se limitan a la creación de una *newco* -denominada NUTRIEN LTD- que se desempeña como la *parent* -o controlante última- de las dos empresas fusionadas, y el consecuente cambio de control sobre PROFERTIL S.A. y AGROSERVICIOS PAMPEANOS S.A. -controladas previamente en forma exclusiva por los accionistas de AGRIMUM INC.- **se encuentra sujeta a la obligación de notificación prescripta en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, lo cual debe ser efectivizado por las partes de la operación o por la sociedad comercial continuadora.**

SEGUNDO: Hacer saber a la consultante que el presente voto disidente ha sido emitido fundamentalmente sobre la base de la información y documentación que se ha proporcionado y que obra en el expediente de referencia; por lo que, si lo presentado y consignado fuera falso o incompleto, ello tornaría -total o parcialmente- inaplicables los conceptos aquí vertidos.

Elévese el Dictamen de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que incluye el presente voto particular, a la Señora SECRETARIA DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO DE LA NACIÓN para su conocimiento.

[1] Obrante en el presente expediente electrónico en su traducción al idioma español .

[2] Ver organigrama presentado por la consultante el 22 de febrero de 2018.

[3] Ver presentación efectuada el 9 de enero de 2018.

[4] Ver organigrama presentado por la consultante el 22 de febrero de 2018.

[5] http://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/NYSE_POT_2016.pdf

[6] Ver presentación de parte del 18 de junio de 2018.

[7] Concepto, referido a exportaciones, desarrollado jurisprudencialmente por la CNDC y actualmente receptado por la Ley 27.442 artículo 11 inciso c), y que queda acreditado por la información allegada por la consultante en presentaciones del 9 de enero, 30 de mayo y 18 de junio, todas de 2018.

[8] Concepto, referido a exportaciones, desarrollado jurisprudencialmente con anterioridad por la CNDC y actualmente receptado por la Ley 27.442 artículo 11 inciso c) y que queda acreditado por la información allegada por la consultante en presentaciones del 9 de enero, 30 de mayo y 18 de junio, todas de 2018.

[9] Conforme artículo 6º inciso de la Ley 25.156

[10] Conforme artículo 8º de la Ley 25.156 (vigente al tiempo de la consulta).

[11] En presentación del 9 de enero de 2018 se indica que las ventas totales 2016 fueron U\$S 364.734.000.-

[12] Ver presentación de parte del 9 de enero de 2018.